RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.993 - SP (2013/0104421-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
R.P/ACÓRDÃO	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA OS CASOS DE ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA E DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR ARREPENDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO DE MULTA EM PROL DO FORNECEDOR PASSÍVEL DE INVERSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Ação civil pública proposta com o objetivo de, sob o imperativo da reciprocidade, impor cláusula penal ao fornecedor de bens móveis, nos casos de atraso na entrega da mercadoria e na demora de restituição do valor pago quando do exercício do direito do arrependimento, ante a premissa de que o consumidor é penalizado com a obrigação de arcar com multa moratória quando atrasa o pagamento de suas faturas de cartão de crédito.

2. Dado que ao Poder Judiciário não é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a "inversão" da cláusula penal deve partir do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC.

3. No caso dos autos, a empresa fornecedora de bens móveis não cobra, no contrato de compra e venda, multa moratória, motivo por que o princípio do equilíbrio contratual não pode ser invocado para impor a multa.

4. No pacto de compra e venda, a empresa fornecedora envia a mercadoria após a confirmação de pagamento pela operadora de cartão de crédito, inexistindo risco de mora, daí a desnecessidade de previsão de cláusula penal, não havendo multa contratual a ser contra ela "invertida".

5. O simples fato de o fornecedor disponibilizar, dentre outros meios de pagamento, em seu sítio da internet, compra por meio de cartão de crédito, de diferentes bandeiras, à escolha do consumidor, não autoriza a imposição de cláusula penal como corolário do equilíbrio contratual.

6. O contrato de compra e venda celebrado entre fornecedor de bens móveis e o consumidor não se confunde com o pacto realizado entre este e a operadora de cartão de crédito de sua preferência, possuindo cláusulas próprias e incomunicáveis.

7. A multa cobrada pela administradora do cartão, em face do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, é contrapartida justificada pela obtenção do crédito de forma fácil e desembaraçada, sem que o consumidor tenha de prestar garantia adicional alguma, além da promessa de pagar no prazo acertado.

8. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, impõe somente a atualização monetária do valor pago pelo comprador nos casos de exercício do direito de arrependimento, de sorte que a imposição de multa moratória, em abstrato, por sentença em ação coletiva, nessa hipótese, carece de previsão legislativa.

9. O estímulo ao cumprimento dos prazos para a entrega de mercadorias e devolução

do pagamento em caso de desistência de compra é efetuado pela dinâmica do próprio mercado, que pune aqueles que prestam serviço deficiente, dispondo os consumidores de variados canais para tornarem públicas suas reclamações e elogios, além de contar com o Poder Judiciário naqueles casos concretos em que a mora do fornecedor ultrapasse os limites da razoabilidade.
10. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Ministro Lázaro Guimarães dando provimento ao recurso especial, acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrará o acórdão.

Vencidos o relator e o Ministro Marco Buzzi. Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região).

Brasília/DF, 08 de maio de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora p/ acórdão

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 01/06/2017 JULGADO: 01/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 01/06/2017 JULGADO: 06/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 01/06/2017 JULGADO: 13/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 01/06/2017 JULGADO: 20/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.993 - SP (2013/0104421-7)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO : RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO-VENCIDO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:

1. Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em face de **Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda**, ora recorrente, atuante do comércio varejista, em estabelecimentos físicos e por meios eletrônicos, sob o argumento de existência de possível caráter abusivo em contrato de adesão elaborado pela ré, por meio do qual negociava com seus consumidores.

Asseverou que, tanto para a hipótese de pagamento a prazo, quanto para a hipótese de atraso no pagamento, ao consumidor impõe-se multa moratória. Sustentou que as abusividades consistiam na inexistência de cláusulas com previsão de prazo de entrega das mercadorias pela ré, fornecedora, assim como de previsão de multa moratória para os casos de impontualidade.

Aduziu que, igualmente, inexistia previsão contratual de prazo para o cumprimento da obrigação da ré de restituir o preço pago, no caso de o consumidor exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, ou quando previa esse prazo, sem estabelecer qualquer sanção para o caso de atraso na devolução.

Concluiu que o equilíbrio do contrato padrão de adesão de compra e venda pressupunha a imposição de prazo para ambas as partes cumprirem suas respectivas obrigações, assim como a previsão de sanções, em desfavor das duas, para a mora.

O sentenciante de piso julgou o pedido da inicial improcedente, salientando a possibilidade de o consumidor que se sentisse de alguma forma lesado, pleitear, individualmente, o que entendesse de direito (fls. 178-182).

Em face da sentença, o autor interpôs apelação (fls. 187-197). Examinando o recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado em ação civil pública, condenando a ré a estabelecer, em todas as suas operações de venda de produtos multa moratória para o caso de atraso na entrega da mercadoria, bem como multa moratória para o eventual atraso na restituição do preço pago pelo consumidor, nas hipóteses de arrependimento previstas no art. 49, parágrafo único, do CDC, no montante de 2% do valor do **produto**, nos termos da

seguinte ementa (fls. 258-259):

> BEM MÓVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Compra e venda de mercadorias fornecidas por grande empresa através do seu *site* na *internet* - Possibilidade de desistência do negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora - Restituição da quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora - Necessidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do produto - Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros legais de 1 % ao mês - Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula penal, mas também o fornecedor - Recurso parcialmente provido.

Foram opostos embargos de declaração pela ré, Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda (fls. 291-296), rejeitados, conforme ementa abaixo (fl. 300):

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - COISAS - BEM MÓVEL - Ação civil pública - Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora apresenta erro de fato, contradição, obscuridade e omissão - Nítido caráter infringente, sem condições de ser provido, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir - Embargos rejeitados.

Sobreveio recurso especial, interposto por Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda (fls. 307-326), com fulcro no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988.

Nas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 395, 396, 421 e 476 do Código Civil de 2002, assim como art. 2º, 4º, III, 39, XII, 49, 51, IV e § 1º, II, todos do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, alega violação ao art. 535 do CPC de 1973.

Sustenta, em primeiro lugar, a inexatidão da afirmação do recorrido, Ministério Público do Estado de São Paulo, no que respeita à assinatura de contrato de adesão e fixação de cláusula penal, porque inexistentes.

Assevera que, em sua loja virtual, após a escolha do produto pelo consumidor, abre-se a oportunidade de escolha da forma de pagamento: cartão de crédito, transferência eletrônica e boleto bancário para pessoas físicas que não expõem a recorrente ao risco de mora, razão pela qual não haveria sentido algum na fixação de multa de mora para o comprador, como de fato não ocorreu.

Informa que, apenas após a realização do pagamento, que é feito à vista, seja por meio de transferência ou boleto, é que a mercadoria é enviada, abrindo-se o prazo de entrega do produto. Por sua vez, se o pagamento é efetuado por cartão de crédito, os riscos de inadimplemento e de mora passam a ser, exclusivamente, da administradora e do

emissor do cartão de crédito, que não possuem qualquer ligação com a recorrente.

Aduz, nessa linha, que, caso o consumidor opte pelo pagamento parcelado, ou, ainda, se o consumidor atrasa no pagamento da fatura de cartão de crédito, os juros cobrados pela mora serão pagos à operadora de cartão de crédito, podendo-se falar, portanto, em desequilíbrio do contrato entre o consumidor e a administradora de cartão de crédito e não entre a recorrente e o consumidor.

A recorrente argumenta que não cobra e, por isso, nunca receberá os juros ou a multa por atraso no pagamento do preço de seus consumidores e, por, conseguinte, com base no princípio do equilíbrio contratual (art. 4º, II, do CDC), não deveria arcar com juros e multa na hipótese de eventual atraso.

Arremata que, nas vendas efetivadas fora do estabelecimento (via *internet*) e por meio de financiamento, únicas que poderiam ter multa moratória ao consumidor pessoa física, não há sua fixação pela recorrente, mas, eventualmente, pela administradora de cartão de crédito, e isso apenas se o consumidor optar por pagamento parcelado ou quando atrasar o pagamento da fatura, constituindo-se o "laço contratual que possui com a administradora, independente do laço contratual que possui com o Recorrente" (fl. 320).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 337-347).

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fl. 356), ascendendo a esta Corte por meio de provimento do agravo de instrumento interposto (fl. 388).

É o relatório.

2. De início, não merece prosperar a apontada violação do art. 535 do CPC, pois as alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284 do STF.

3. A principal controvérsia dos autos consiste em definir a possibilidade ou não de inclusão de multa moratória em contratos celebrados entre consumidores e empresa de comércio varejista, para as hipóteses em que descumprir prazo ajustado para entrega dos produtos que comercializa, assim como para a hipótese de descumprir o prazo fixado de restituição dos valores pagos pelo consumidor, quando exercido seu direito de arrependimento.

A presente demanda teve origem em inquérito civil instaurado no ano de 2008, para apurar irregularidades referentes, principalmente, ao prazo de entrega das mercadorias, que seriam praticadas por treze empresas de comércio varejista, entre elas a ora recorrente,

Kalunga.

Na verdade, outras ações, frutos daquele inquérito, chegaram a este Sodalício, em sede de recursos especiais, como o **REsp n. 1.548.189/SP**, em julgamento recentemente concluído pela Egrégia Terceira Turma, sob a relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O Ministro relator proferiu voto negando provimento ao recurso especial, **mantendo a determinação do acórdão consistente na inclusão, nos contratos de venda, de multa de 2% sobre o valor da venda, no caso de descumprimento do prazo de entrega e da obrigação de devolução do preço, uma vez exercido o arrependimento do consumidor, o que acabou prevalecendo por maioria.**

Outrossim, anoto que há outro caso de varejista, oriundo do mesmo inquérito, em recurso especial concluso ao Gabinete da Ministra Maria Isabel Gallotti. Sua Excelência havia negado provimento ao recurso, mas, após a interposição de agravo regimental houve reconsideração da decisão e aguarda-se novo exame.

4. No caso ora em exame, a sentença manifestou-se acerca dos seguintes pontos: *1)* fixação de prazo para entrega dos produtos; *2)* fixação de prazo para devolução dos valores ao consumidor que desiste da compra e multa nos casos de atraso nessa devolução; *3)* multa pelo descumprimento da entrega da mercadoria no prazo estipulado (fls. 180-182):

> **No que diz ao pedido de estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação da Ré, especialmente quanto à entrega da mercadoria, o documento de fls. 88, oriundo do sitio da Ré na *internet*, é claro ao apontar os prazos de entrega, de acordo com o valor gasto pelo cliente, pelo local de entrega da mercadoria e a forma de transporte por ele eleita**.
> **Assim, desnecessária a inclusão de prazo para o cumprimento da obrigação consistente em entregar a mercadoria, pois, como visto, dito prazo já consta nas informações dadas ao cliente pela Ré.**
> Com relação à hipótese em que há **desistência do negócio por parte do comprador (especificamente aquele que adquire bens à distância, ou seja, pelo telefone ou pela *internet*)**, respeitado o entendimento do Ministério Público, **tem-se que não há como ser acolhida a sua pretensão**.
> **É que, segundo a regra do artigo 49, parágrafo único, da Lei Federal 8.078/90, tendo o consumidor demonstrado a desistência, a devolução de valores deve ser imediata e com correção de valores.**
> Ora, a lei já prevê a situação de arrependimento do consumidor, de modo que, nesse pertinente, não assiste razão ao Ministério Público.
> A lei já prevê a obrigação do fornecedor se o consumidor pretender desistir da compra.
> **Tampouco há que se cogitar de aplicação de multa, pois a lei não prevê essa disposição.**
> (...)
> **Também não há que ser acolhido o pedido referente à imposição de multa contratual para o caso de descumprimento da obrigação de**

> **entregar a mercadoria no prazo estipulado em contrato e para a hipótese de não devolução imediata do valor pago em caso de desistência oportuna por parte do consumidor.**
> É que, no ver deste Juízo, respeitados entendimentos contrários, não se aplica ao caso concreto as disposições do artigo 84 da Lei Federal 8.078/90 e artigo 11 da Lei Federal 7.347/85.
> Assim entendo, pois, nem um, nem outro dos dispositivos citados se referem à aplicação de multa de modo genérico.
> Ao revés, a multa prevista nos mencionados tipos legislativos é vinculada a uma obrigação de fazer não cumprida, o que será objeto de apreciação em processo judicial, garantido o contraditório.
> Portanto, multa, segundo a legislação, deve ser aplicada no caso concreto e não de forma genérica.

No entanto, de modo diferente entendeu o acórdão recorrido, que reformou a sentença, dando provimento aos pedidos iniciais, mormente no que respeitava à inserção nos contratos das multas por descumprimento de prazo de entrega dos produtos e dos valores pagos em caso de arrependimento do consumidor. Confiram-se (fls. 281-287):

> A Kalunga comprovou documentalmente que já vinha cumprindo o primeiro item do pedido ministerial, porquanto disponibiliza em seu endereço eletrônico a informação quanto ao prazo de entrega do produto adquirido, que varia de 1 a 5 dias úteis após a confirmação do pagamento, consoante se vê a fls. 88/89.
> (...)
> No que toca à desistência da compra realizada via internet (...) Infere-se que as informações relativas ao procedimento para devolução de mercadoria, em caso de arrependimento estão dispostas no site da ré, onde está previsto, inclusive, que a restituição do preço pago será efetivada em até 10 úteis ou estorno na fatura do cartão de crédito (fls. 93).
> **Portanto, resta analisar os pedidos de cominação de multa à ré para os casos de eventual atraso na entrega da mercadoria ou atraso na restituição do preço pago pelo consumidor quando há devolução do produto.**
> (...)
> Aduziu a ré na contestação, que, a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal porquanto inexiste risco de mora, uma vez que as vendas pela *internet* são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito, de modo que somente após a confirmação do pagamento é que, começa a correr o prazo para a entrega do produto.
> **Entretanto, com a devida vênia, na hipótese em testilha, vislumbra-se a cobrança de multa moratória em caso de atraso no pagamento do preço do produto por parte do consumidor, eis que há financiamento oferecido pela ré em seu *site*, para compra das mercadorias em parcelas, como se vê dos documentos de fls. 94/105**.
> Ora, como bem asseverou o ilustre Promotor de Justiça por ocasião da réplica, "irrelevante que a multa moratória devida pelo consumidor reverta em beneficio da financeira. A ré fala do financiamento no caso de pagamento parcelado como se absolutamente nada tivesse com o negócio. Mas o financiamento do preço ainda que realizado por instituição financeira,

> é (...) negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria. O financiamento é oferecido por ela própria, notadamente em seu sítio de *Internet*, como demonstram os documentos que acompanham a contestação" (fls. 119).
> **Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade e rompimento do equilíbrio contratual.**
> (...)
> **Destarte, considerando os prazos de entrega das mercadorias adquiridas no site da ré, bem como o prazo de restituição do valor pago por elas em caso de desistência do consumidor, conforme ali disposto, necessária a fixação de multa para o caso de desrespeito a tais prazos por parte da fornecedora, que deve ser no montante de 2% do valor do produto, acrescido de juros legais de 1 % ao mês.**

5. A defesa do consumidor encontra seu fundamento na Constituição, sua regulamentação efetivou-se, igualmente, por expressa determinação constitucional (art. 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias), sendo, pois, imperioso o reforço na dimensão constitucional-protetiva do Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, preparou o mercado brasileiro para o século XXI e consolidou uma nova ética empresarial, apoiada na visão moderna de valorização do consumidor como técnica eficaz, capaz de se diferenciar da concorrência e ampliar a fidelidade dos clientes.

Após quase trinta anos de existência, apesar de possuir normas de vanguarda, o progresso considerável das técnicas de contratação a distância, as inovações tecnológicas e o crescente comércio eletrônico de consumo, assim como a democratização do crédito, mostraram razões suficientes para que fosse instituída, no Senado Federal, Comissão de Juristas incumbida de aperfeiçoar o diploma consumerista

Nesse passo, a primeira questão a ser enfrentada nessa seara diz respeito à suficiência das normas jurídicas existentes para abranger as relações estabelecidas por meio do comércio eletrônico, por exemplo. Discorrendo sobre a regulação jurídica do comércio eletrônico e a necessidade de maior proteção dos vulneráveis nos sistemas de troca por intermédio da *internet*, Claudia Lima Marques ensina que aquele comércio possui uma *unilateralidade visível* e uma *bilateralidade escondida*, querendo indicar o desafio à correta compreensão do exercito da liberdade contratual nas transações estabelecidas e o surgimento de uma nova *vulnerabilidade eletrônica*.

Ensina a professora, especialista no tema, que o art. 49 do CDC inova o ordenamento jurídico nacional e institui prazo de reflexão obrigatório e um direito de arrependimento, para proteger a declaração de vontade do consumidor, para que essa possa ser decidida e refletida com calma, protegida das técnicas de venda a domicílio (*Comentários ao código de defesa do consumidor.* 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 911).

No caso do comércio eletrônico (internet), pondera, por sua vez, Leonardo

Roscoe Bessa, que a razão do direito de arrependimento é a impossibilidade de contato físico com o produto. "Por mais que se mostrem diversas fotos, sejam esclarecidas as características e qualidades do produto, nada substitui o contato direto do consumidor com o bem, fator imprescindível para uma decisão de compra". (*Manual de direito do consumidor. Proteção contratual.* 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 292)

Assenta o art. 49 do CDC:

> O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
> **Parágrafo único**. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Segundo dispõe o parágrafo único transcrito acima, exercitado o direito de arrependimento, não deverá haver enriquecimento ilícito do fornecedor, em virtude de sua prática agressiva de venda. "Desconstituído o vínculo pela manifestação do consumidor, retornarão ambos os contratantes ao *status* anterior, devendo o fornecedor devolver os valores recebidos, monetariamente atualizados" (MARQUES, Claudia Lima. *Op. cit*, p. 917).

6. No entanto, no caso ora em exame, o Ministério Público de São Paulo reivindica providência para situação que vai além do ressarcimento integral de direito do consumidor. Na verdade, pleiteia o *Parquet* a inserção de cláusulas contratuais, no contrato de adesão por meio do qual a recorrente pactua com seus consumidores, que preveja multa para os casos em que houver descumprimento no **prazo de entrega dos produtos** que comercializa. Da mesma forma, requer o autor da ação civil a inserção de cláusula com previsão de multa para o descumprimento do **prazo de devolução daqueles valores pagos** pelo consumidor que exercitou o direito de arrependimento referenciado alhures.

A argumentação central do Ministério Público assenta-se, principalmente, no desequilíbrio contratual, no fato de tais penalidades serem uma realidade para o consumidor e não haver a devida contraprestação por parte do fornecedor. Assevera que há, no sítio eletrônico da recorrente, Kalunga, confirmado pelo acórdão, inclusive, a opção de financiamento para o caso de pagamento parcelado, com previsão de multa moratória para os casos de inadimplemento do consumidor das parcelas devidas, sendo irrelevante o fato de os valores pagos a título de juros e multas reverterem-se a favor da varejista, já que o financiamento é disponibilizado em favor do negócio que realiza, para incrementá-lo**.**

No que respeita ao princípio do equilíbrio, em direito do consumidor, não se pode perder de vista, que, ao lado do princípio da vulnerabilidade, se revela como resultado do reconhecimento da desigualdade nas relações de consumo, e a necessidade da preservação

do direito do consumidor, cuja finalidade específica será sempre garantir o equilíbrio dos interesses entre as partes da relação contratual.

Nessa toada, cumpre ressaltar, quanto ao desequilíbrio contratual gerado pela prática alegadamente abusiva, consistente na previsão de obrigações para a parte hipossuficiente da relação, que não encontra correspondência em relação à outra, que o Código de Defesa do Consumidor optou por fórmulas abertas para anunciar as chamadas "práticas abusivas" e "cláusulas abusivas", lançando mão de um rol meramente exemplificativo para descrevê-las. Daí a menção não exauriente contida nos arts. 39 e 51, *verbis*:

> Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...];
> Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que [...].

As técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem levar em conta o art. 4º daquele diploma, o qual contém uma espécie de lente pela qual devem ser examinados os demais dispositivos, notadamente por estabelecer os objetivos da política nacional das relações de consumo e princípios que devem ser respeitados - entre os quais se destacam, no que interessa ao caso concreto, a "harmonia das relações de consumo" e o "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores".

O magistério de Eros Roberto Grau explicita bem a forma pela qual devem ser entendidos os objetivos e princípios adotados pelo CDC, sobretudo, no artigo 4º:

> (...) eu diria que o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor é uma norma-objeto, porque define os fins da política nacional das relações de consumo, quer dizer, ela define resultados a serem alcançados. Todas as normas de conduta e todas as normas de organização, que são as demais normas que compõem o Código do Consumidor, instrumentam a realização desses objetivos, com base nos princípios enunciados no próprio art. 4º. Para que existem, por que existem essas normas? Para instrumentar a realização dos fins definidos no art. 4º. Assim, **todas as normas de organização e conduta contidas no Código do Consumidor, devem ser interpretadas teleologicamente, finalisticamente, não por opção do intérprete, mas porque essa é uma imposição do próprio Código. O que significa isso? Sabemos que a interpretação não é uma ciência, é uma prudência. Nela chegamos a mais de uma solução correta, tendo de fazer uma opção por uma delas. A circunstância de existirem normas-objeto que determinam a interpretação de normas de organização e de conduta estreita terrivelmente a possibilidade dessa opção, porque a única interpretação correta é aquela que seja adequada à instrumentação da realização dos fins, no caso, os fins estipulados no art. 4º do CDC.**
> (GRAU, Eros Roberto. *Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor. Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.)*. São Paulo: RT, 2011 (Coleção doutrinas essenciais, v. I), p. 165-166).

A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4º, inciso III), tem-se também como um direito básico do consumidor a "igualdade nas contratações" (art. 6º, inciso II) e outros direitos não previstos no CDC, mas que derivem "dos princípios gerais de direito" e da "equidade" (art. 7º).

Não fosse o bastante, o art. 51, ao enumerar algumas cláusulas tidas por abusivas, deixa claro que, nos contratos de consumo, deve haver reciprocidade de direitos entre fornecedores e consumidores, mostrando-se abusivas, por exemplo, as cláusulas contratuais que:

> IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
> XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
> XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Relevante notar também que a Portaria n. 4, de 13.3.1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ), previu como abusivas e, portanto, nulas, as cláusulas que: "... estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da obrigação somente em desfavor do consumidor".

Ressalte-se, por outro lado, que as disposições contidas em normas infralegais, por expressa disposição do CDC, inserem-se na categoria de outros direitos "decorrentes (...) de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes" (art. 7º, CDC).

Finalmente, ressalto que essa tendência é mundial, de se exigir reciprocidade entre as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor, tendo sido adotada na Diretiva n. 93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Européia (CEE), de 5.4.93, nos termos do art. 1º, alínea "d", do Anexo:

> 1. Cláusulas que têm como objetivo ou como efeito:
> [...]
> d) Permitir ao profissional reter montantes pagos pelo consumidor se este renunciar à celebração ou execução do contrato, sem prever o direito de o consumidor receber do profissional uma indenização de montante equivalente se for este a renunciar.

Extrai-se do mesmo documento, aliás, diretivas específicas sobre esse debate, quais sejam**, regras de condutas atinentes ao comércio eletrônico**, orientadas pela interpretação do *favor debilis* e pela presunção de vulnerabilidade do consumidor. Confiram-se os seguintes tópicos destacados abaixo:

> (38) Os sítios Internet dedicados ao comércio deverão indicar, de forma

clara e legível, o mais tardar no início do processo de encomenda, a eventual aplicação de restrições à entrega e quais os meios de pagamento aceites.

(43) Se o profissional não informar adequadamente o consumidor antes da celebração de um contrato à distância ou fora do estabelecimento comercial, o prazo de retractação deverá ser alargado. Contudo, a fim de garantir a segurança jurídica no que respeita à duração do prazo de retractação, deverá ser introduzido um prazo de prescrição de 12 meses.

(46) No caso de o consumidor se retractar do contrato, o profissional deverá reembolsar todos os pagamentos recebidos do consumidor, nomeadamente os relativos às despesas suportadas pelo profissional para entregar os bens ao consumidor. O reembolso não deverá ser feito sob a forma de uma nota de crédito, salvo se o consumidor tiver usado notas de crédito na transacção inicial ou de forma expressa as tiver aceitado. Se o consumidor escolher expressamente um determinado tipo de entrega (por exemplo, entrega urgente em 24 horas), apesar de o profissional ter oferecido um tipo de entrega comum e geralmente aceite e com custos de entrega inferiores, a diferença de custo entre os dois tipos de entrega deverá ser suportada pelo consumidor.

(48) O consumidor deverá ser obrigado a devolver os bens no prazo máximo de 14 dias após ter informado o profissional da sua decisão de retractação do contrato. **Nos casos em que o profissional ou o consumidor não cumpra as obrigações relativas ao exercício do direito de retractação, deverão ser aplicáveis as sanções previstas na legislação nacional nos termos do disposto na presente directiva, bem como as disposições em matéria de direito dos contratos**.

(52) No contexto dos contratos de venda, a entrega de bens pode ter lugar de várias maneiras, imediatamente ou numa data posterior. Se as partes não tiverem acordado uma data de entrega específica, o profissional deverá proceder à entrega dos bens o mais rapidamente possível, mas, em qualquer caso, pelo menos até 30 dias a contar da data de celebração do contrato. A regra respeitante à entrega tardia deverá também ter em conta os bens a fabricar ou a adquirir especialmente para o consumidor e que não podem ser reutilizados pelo profissional sem perda considerável. Por conseguinte, deverá ser prevista na presente directiva uma norma que conceda ao profissional um prazo adicional razoável em certas circunstâncias. Sempre que o profissional não entregar os bens dentro do prazo acordado com o consumidor, antes de o consumidor poder rescindir o contrato, o consumidor deverá solicitar ao profissional que proceda à entrega dentro de um prazo adicional razoável e ter o direito de rescindir o contrato se o profissional não entregar os bens dentro desse prazo adicional. Todavia, esta norma não deverá ser aplicável quando o profissional tiver recusado proceder à entrega dos bens numa declaração inequívoca. Também não deverá ser aplicável se, em certas circunstâncias, o prazo de entrega constituir um elemento essencial como, por exemplo, no caso de um vestido de noiva, que deverá ser entregue antes do casamento. Também não deverá ser aplicável se o consumidor tiver informado o profissional de que é essencial que a entrega seja efectuada numa data específica. Para o efeito, o consumidor poderá usar os elementos de contacto do profissional comunicados nos termos da presente directiva. Nestes casos específicos, se o profissional não proceder atempadamente à

> entrega dos bens, o consumidor deverá ter o direito de rescindir o contrato imediatamente após a expiração do prazo de entrega inicialmente acordado. A presente directiva não deverá prejudicar as disposições nacionais relativas à forma como o consumidor deve notificar o profissional da sua intenção de rescindir o contrato.
> (53) **Além do direito do consumidor de rescindir o contrato no caso de o profissional não cumprir as suas obrigações no que se refere à entrega dos bens nos termos da presente directiva, o consumidor pode, ao abrigo da legislação nacional aplicável, recorrer a outras soluções, como conceder ao profissional um prazo adicional para a entrega, impor a execução do contrato, reter o pagamento e pedir indemnização.**
> (57) **É necessário que os Estados-Membros determinem as sanções aplicáveis à violação do disposto na presente directiva e garantam a sua aplicação. Essas sanções deverão ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.**

Assim, a meu juízo, seja por princípios gerais do direito, ou pela linha adotada no Código, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações de análogo descumprimento da avença.

Desse modo, penso que, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento.

No caso sob exame, penso, aliás, que a multa fixada pelo acórdão de origem tem indiscutível caráter disciplinar, muito mais que repressor. É didático seu maior papel. O objetivo de sua instituição e, após, a fixação em concreto, não é o recolhimento, em si, do numerário a ela equivalente. Esse é o meio para alcance do fim maior que se persegue, qual seja, que não haja o descumprimento do contrato, mas que, ao revés, haja **entrega do produto no prazo avençado** ou do **valor devido pela desistência da compra, também no prazo estipulado** como razoável para esse acontecimento.

É preciso deixar bem claro, não interessa ao consumidor ou à sociedade, ou interessa menos, o recebimento da multa, com relação ao adimplemento da obrigação na forma e prazo acordado.

A inserção nos contratos, como dos autos, da multa moratória visa, acima de qualquer coisa, garantir ao consumidor o cumprimento perfeito da avença, a não frustração de suas expectativas.

Ressalte-se, ademais, que não prospera a alegação da recorrente no sentido de que a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal nas compras a vista, pelo simples motivo de inexistir risco de mora, uma vez que as vendas pela *internet* são feitas por

transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito, de modo que somente após a confirmação do pagamento é que começa a correr o prazo para a entrega do produto.

A assertiva da recorrente, em verdade, opera em seu desfavor, uma vez que não é difícil alcançar o raciocínio de que, na verdade, a recorrente não precisa da imposição de multa para garantia do cumprimento da obrigação do consumidor, justamente porque sua maior garantia é o próprio cumprimento da obrigação pelo consumidor, já que, enquanto ele não aperfeiçoa sua obrigação (paga o preço), a recorrente não cumpre sua tarefa de entregar o produto. Não há razão na instituição da multa nas compras à vista, portanto.

Da mesma forma, não prospera a alegação da recorrente no sentido da impossibilidade de imposição de multa em seu desfavor, tendo em vista o fato de que aquela penalidade é arbitrada pela instituição financeira, sendo ela a verdadeira responsável pelo contrato de financiamento oferecido aos compradores da loja virtual.

Não há como acolher aludido argumento porque, em última análise, e indiscutivelmente, tal financiamento é manifesto incentivador/facilitador dos negócios que se realizam no ambiente virtual. A recorrente tem pleno conhecimento de que não fosse a opção oferecida de compras via cartão de crédito, em parcelas, ou outro tipo de financiamento, suas vendas seriam sensivelmente diminuídas. Ou seja, interessa ao fornecedor a opção de pagamento consubstanciado naquele financiamento que a recorrente afirma ser titularizado por pessoa diversa.

Ademais, há de se considerar que ao contratar tal forma de pagamento, o consumidor não tem em mente que contrata com pessoa diferente da recorrente varejista que dá nome à loja na qual "entrou" para realizar suas compras! Não é com a financeira que o consumidor ao menos *deseja* contratar, mas com a fornecedora dos produtos, no caso, a Kalunga Comércio e Indústria.

7. A solução que se apresenta não é inédita, tendo esta Colenda Turma, na ocasião do julgamento do REsp n. 955.134/SC, reconhecido a possibilidade de extensão de regra contratual com previsão de multa moratória em desfavor do comprador de imóvel aos casos de inadimplemento do vendedor, quando referida penalidade não se encontrava prevista, originalmente, no acordo firmado entre as partes, com base em fundamentos aqui invocados.

Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:

> DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA (VENDEDOR). DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO USO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO, A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA, DE LAUDO CONFECCIONADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA PARTE

VENCEDORA. DESCABIMENTO. EXEGESE DOS ARTS. 19 E 20 DO CPC. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA MULTA EXCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

1. Apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por culpa da construtora (fornecedor), é devido o pagamento de aluguéis, pelo adquirente (consumidor), em razão do tempo em que este ocupou o imóvel. O pagamento da verba consubstancia simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante determinado interregno temporal, rubrica que não se relaciona diretamente com danos decorrentes do rompimento da avença, mas com a utilização de bem alheio. Daí por que se mostra desimportante indagar quem deu causa à rescisão do contrato, se o suporte jurídico da condenação é a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes.

2. **Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações de análogo descumprimento da avença. Assim, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento. Assim, mantém-se a condenação do fornecedor - construtor de imóveis - em restituir integralmente as parcelas pagas pelo consumidor, acrescidas de multa de 2% (art. 52, § 1º, CDC), abatidos os aluguéis devidos, em vista de ter sido aquele, o fornecedor, quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.**

3. Descabe, porém, estender em benefício do consumidor a cláusula que previa, em prol do fornecedor, a retenção de valores a título de comissão de corretagem e taxa de serviço, uma vez que os mencionados valores não possuem natureza de cláusula penal moratória, mas indenizatória.

4. O art. 20, caput e § 2º, do Código de Processo Civil enumera apenas as consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as "despesas" que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles "endoprocessuais" ou em razão do processo, quais sejam, "custas dos atos do processo", "a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico". Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência, de valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua confiança. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 955.134/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012)

8. Por fim, resta salientar, a título apenas de registro, que o aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor conta com capítulo específico atinente ao comércio eletrônico e, entre as inovações sugeridas pela Comissão responsável pela elaboração do Projeto de Lei de alteração, percebe-se a preocupação com a inclusão de institutos que dêem eficácia aos princípios informadores desse ramo do direito.

Nessa linha, confiram-se os artigos do CDC, com redação proposta pelo PL n. 3.514/2015, em tramitação na Câmara dos Deputados, no que respeita ao comércio eletrônico, numa tentativa clara de dar efetividade aos comandos originais do diploma do consumidor.

> Art. 49. O consumidor pode desistir da contratação a distância no prazo de 7 (sete) dias a contar da aceitação da oferta, do recebimento ou da disponibilidade do produto ou serviço, o que ocorrer por ultimo.
> § 1º .....
> § 2º Por contratação a distancia entende-se aquela efetivada fora do estabelecimento ou sem a presença física simultânea do consumidor e do fornecedor, especialmente em domicilio, por telefone, por reembolso postal ou **por meio eletrônico ou similar**.
> § 3º Equipara-se à modalidade de contratação prevista no § 2º deste artigo aquela em que, embora realizada no estabelecimento, o consumidor não tenha tido a prévia oportunidade de conhecer o produto ou serviço, por não se encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou dificuldade de acesso a seu conteúdo.
> § 4º A desistência formalizada dentro do prazo previsto no *caput* implica a devolução do produto, com todos os acessórios recebidos pelo consumidor e a nota fiscal.
> § 5º Caso o consumidor exerça o direito de arrependimento, inclusive em operação que envolva retirada de recursos ou transação de financiamento, os contratos acessórios de crédito são automaticamente rescindidos, devendo ser devolvido ao fornecedor do crédito o valor total financiado ou concedido que tiver sido entregue, acrescido de eventuais juros incidentes até a data da efetiva devolução, tributos e tarifas, sendo estas cobradas somente quando aplicável.
> § 6º Sem prejuízo da iniciativa do consumidor, o fornecedor deve comunicar de modo imediato a manifestação do exercício de arrependimento à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, a fim de que:
> I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor;
> II - seja efetivado o estorno do valor, caso a fatura já tenha sido emitida no momento da comunicação;
> III - caso o preço já tenha sido total ou parcialmente pago, seja lançado o crédito do respectivo valor na fatura a ser emitida posteriormente à comunicação.
> § 7º Se o fornecedor do produto ou serviço descumprir o disposto no § 1º ou no § 6º, o valor pago será devolvido em dobro.
> § 8º O fornecedor deve informar, de forma prévia, clara e ostensiva, os meios adequados, facilitados e eficazes disponíveis para o exercício do direito de arrependimento do consumidor, que devem contemplar, ao menos, o mesmo modo utilizado para a contratação.
> § 9º O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação individualizada e imediata do recebimento da manifestação de arrependimento.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 2251233220088260100 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 01/06/2017 JULGADO: 27/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA HILDA MARSIAJ PINTO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do relator negando provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA antecipada a Ministra Maria Isabel Gallotti.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.993 - SP (2013/0104421-7)

VOTO-VISTA

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial interposto por KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

> BEM MÓVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Compra e venda de mercadorias fornecidas por grande empresa através do seu site na internet - Possibilidade de desistência do negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora - Restituição da quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora - Necessidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do produto - Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros legais de 1% ao mês - Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula penal, mas também o fornecedor - Recurso parcialmente provido.

Contra o referido julgado, foram opostos embargos declaratórios, cujo acórdão recebeu a ementa assim lavrada:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO COISAS BEM MÓVEL - Ação civil pública - Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora apresenta erro de fato, contradição, obscuridade e omissão - Nítido caráter infringente, sem condições de ser provido, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir - Embargos rejeitados.

A recorrente interpôs recurso especial, em cujas razões sustentou que o acórdão estadual é omisso; nas vendas realizadas em sua loja virtual não há assinatura de contrato de adesão com fixação de cláusula penal; mesmo que fosse firmado contrato, não haveria sentido algum em se fixar multa moratória porque as formas de pagamento para pessoas físicas – cartão de crédito, transferência eletrônica e boleto bancário – não expõem o recorrente ao risco da mora; o pagamento por meio de cartão

de crédito lhe é repassado pela operadora do cartão, e é esta que assume o risco da inadimplência; que nos pagamentos efetuados por transferência eletrônica e boleto bancário, recebe o preço do produto à vista; não pode ser penalizada por oferecer aos seus consumidores diversos meios de pagamento; não cobra e nunca receberá os juros ou multa por atraso no pagamento do preço de seus consumidores; a imposição de cláusula penal nos casos de atraso na entrega de mercadorias, ou na restituição do valor pago nos casos de arrependimento do consumidor, viola o princípio do equilíbrio contratual; a parte dispositiva abarcou também a forma de pagamento faturada, exclusiva de pessoas jurídicas que não se encontram sob o manto protetor das normas consumeristas; a multa, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada eventual descumprimento na fixação da multa moratória é exorbitante, merecendo redução.

A Corte de origem, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial, decisão que foi impugnada por meio de agravo em recurso especial.

Ao examinar os temas suscitados no agravo, o Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, houve por bem dar provimento ao agravo para melhor exame do recurso especial. Negou provimento, todavia, ao pedido de reforma, sob o fundamento de que o acórdão estadual não é omisso; o REsp n. 1.548.189/SP, julgado pela Terceira Turma, em caso semelhante, manteve a determinação de imposição de multa, conforme estabelecido pela Corte de origem; a inserção de cláusulas contratuais no pacto de adesão é providência que atende ao equilíbrio contratual, já que o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade; a abusividade de cláusulas que estabelecem sanções em caso de atraso ou descumprimento de obrigação somente em desfavor do consumidor é reconhecida pela Portaria n. 4 de 13.3.1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ); tal entendimento corresponde a tendência mundial, como se colhe do exame da Diretiva n. 93/13 do Conselho da Comunidade Econômica Européia (CEE), de 5.4.1993; a recorrente se aproveita da facilidade de oferecer o pagamento por meio de cartão de crédito para fomentar suas vendas; por ocasião do julgamento do REsp n. 955.134/SC, o STJ reconheceu a possibilidade de estender a multa moratória em desfavor do comprador de imóvel no caso de inadimplemento do vendedor, quando a referida penalidade não se encontrava prevista no acordo original firmado entre as partes; o PL n. 3.514/2015, em tramitação na Câmara dos Deputados, tenta dar efetividade aos comandos originais do CDC para resguardar os direitos do consumidor quando atua no comércio eletrônico.

É o relatório.

Logo de início é importante frisar que o entendimento que consta do precedente citado pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp n. 955.134/SC,

também de sua relatoria – não pode ser, data vênia, aplicado no caso dos autos.

Com efeito, o paradigma diz respeito à inversão de cláusula penal em determinado contrato de compra e venda de imóvel. A cláusula foi expressamente pactuada pelos contratantes, entretanto só favorecia um deles – o vendedor. A Quarta Turma entendeu por bem que, em face do princípio do equilíbrio contratual, a cláusula poderia ser invertida para também penalizar o vendedor em face dos transtornos causados pela sua mora.

Já o caso em exame decorre da pretensão do Ministério Público de impor a pactuação de multa moratória em desfavor da empresa ré, porque esta nunca é penalizada em razão da sua mora, enquanto o consumidor sempre responde com a incidência de cláusula penal quando atrasa o pagamento de suas prestações. Embora não haja, no contrato de adesão em tela, previsão contratual de multa que reverta à vendedora em caso de mora do consumidor, este arcará com multa em prol da instituição financeira responsável pela concessão do crédito, quando a compra for financiada. Trata-se, portanto, de situação diversa da apreciada pela Turma no precedente mencionado.

Como já relatado, a sentença havia julgado o pedido improcedente. Ao julgar a apelação do Ministério Público, o voto condutor do acórdão delimitou o âmbito de procedência do pedido, afirmando que não tem sentido impor a multa contratual nas compras realizadas nos estabelecimentos físicos da empresa ré (86,96%), porque a mercadoria é entregue à vista. Segue então argumentando que também as vendas por telefone (4,92%) não podem dar ensejo à multa postulada na ação civil pública, porque efetuadas apenas por pessoas jurídicas que, segundo o acórdão, não se caracterizam como consumidoras, de modo que sobram 7,12% das vendas, apenas as concretizadas na *internet,* as quais podem ser objeto da imposição da multa contratual (fl. 282 e-STJ). Ao justificar a procedência do pedido, considera o seguinte:

> Ora, como bem asseverou o ilustre Promotor de Justiça por ocasião da réplica, *"irrelevante que a multa moratória devida pelo consumidor reverta em benefício da financeira. A ré fala do financiamento no caso de pagamento parcelado como se absolutamente nada tivesse com o negócio.*
> *Mas o financiamento do preço, ainda que realizado por instituição financeira, é (...) negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria. O financiamento é oferecido por ela própria, notadamente em seu sítio de Internet, como demonstram os documentos que acompanham a contestação"* (fls. 119).
> Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora,

sob pena de desigualdade e rompimento do equilíbrio contratual.

Notamos, então, que o fundamento para instituir a multa moratória em detrimento da empresa ré seria a aplicação do princípio do equilíbrio contratual. A empresa estaria estabelecendo a multa em seu sítio da *internet*, quando do financiamento do preço, ainda que indiretamente, por meio de instituição financeira, em "negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria".

Postulou a recorrente, em embargos de declaração, fosse esclarecido que a multa deveria ser imposta apenas nas compras realizadas pela *internet*, como delimitado anteriormente, e nas modalidades onde é empregado o financiamento com auxílio de instituição financeira.

Os embargos de declaração foram rejeitados, mas penso que está claramente definido no acórdão que a multa foi imposta apenas nas compras realizadas pela internet. Por outro lado, não seria coerente que eventual atraso na entrega do produto vendido com o uso de cartão de crédito fosse sancionado com multa em prol do consumidor e idêntico benefício não fosse estendido ao consumidor que pagou à vista, por meio de transferência ou boleto bancário. A falta de nexo do único fundamento invocado pelo acórdão - inversão da multa prevista apenas contra o consumidor - quando, sequer em tese, tal multa poderia onerá-lo, nos casos de pagamento à vista em compra pela internet, guarda relação com o mérito da pretensão e será examinado adiante.

Afasto, portanto, a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC.

Passo ao exame do mérito do pedido inicial.

O acórdão estadual indica que a empresa recorrente estaria impondo ao consumidor o pagamento de multa moratória, e, em face do princípio do equilíbrio contratual, erigido no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, necessária a imposição da mesma penalidade à empresa, quando houver atraso no envio da mercadoria e demora na restituição do valor adiantado nas vendas canceladas em face do exercício do direito de arrependimento.

Especificamente no que se refere à imposição da multa por parte da empresa, o acórdão é obscuro, apontando os documentos de fls. "94/105" (fls. 122/133 e-STJ) como indicativos dessa cobrança. Esses documentos, todavia, são apenas cópias impressas de várias telas da loja virtual da empresa, em que se encontram descritas várias formas de pagamento com suas especificações, sem se referirem uma única vez à cobrança de cláusula penal ou multa moratória.

Infere-se, portanto, que o acórdão estaria se referindo à forma de pagamento por meio de cartão de crédito. As outras modalidades dizem respeito a pagamento à vista e faturado - este último, apesar da possibilidade de parcelamento,

também não apresenta referência alguma à multa moratória, sendo, ademais, privativo de clientes pessoas jurídicas, aos quais negada a proteção do CDC pelo próprio acórdão recorrido.

Assim, **não é a empresa recorrente que está cobrando, diretamente, a multa moratória de seus clientes;** depreende-se da leitura do julgado estadual que **o simples fato de permitir a compra por meio de cartão de crédito autorizaria a imposição de cláusula penal à empresa ré**, como corolário do equilíbrio contratual. Se a compra é realizada por meio de cartão de crédito, e a parte pode ser penalizada pelo seu atraso no pagamento da fatura com a multa contratual, a empresa vendedora do bem também deveria ser penalizada nos casos em que incorrer em mora.

A manutenção desse raciocínio para justificar a imposição da pena à empresa, entretanto, enfrenta uma série de dificuldades.

Em primeiro lugar, a loja permite a utilização de diversas bandeiras de cartão de crédito. Em nenhum momento foi investigado se todas essas operadoras cobram a referida multa, e em que percentual. Assim, a imposição da multa ao consumidor quando do inadimplemento **não passa de uma suposição**, e o seu percentual, nos casos em que efetivamente cobrada, é incerto.

Em segundo lugar, o contrato de cartão de crédito não pode ser chamado de acessório ao pacto de compra e venda, a não ser no sentido mais lato do vocábulo, de servir como instrumento para a realização do negócio. Na verdade se trata de pactos autônomos, **com fornecedores de serviços diversos (compra e venda e financeiro) e cláusulas diferentes e incomunicáveis.**

De forma alguma, data maxima vênia, o contrato de cartão de crédito pode ser considerado "umbilicalmente" ligado ao contrato de compra e venda. O consumidor dispõe de diversos outros meios de pagamento, conforme acima explicitado, e, portanto, não depende apenas de determinado cartão para efetuar compras no *site* da recorrente, sendo, ademais, diversas as bandeiras de cartão aceitas como meio de pagamento.

No pacto entre o consumidor e a operadora de cartão não se pode cogitar de desequilíbrio contratual, uma vez que a cobrança de encargos moratórios é contrapartida contratual e legalmente prevista diante da mora do consumidor, que obteve o crédito de forma fácil e desembaraçada, sem prestar garantia adicional alguma além da promessa de pagar no prazo acertado.

Quebra de contrato pela administradora do cartão haveria se esta não se desincubisse da obrigação assumida com o consumidor de autorizar a compra e repassar o pagamento ao vendedor do produto. Mas disso não se cogita na presente ação civil pública, a qual não se volta contra a administradora ou financeira do cartão de

crédito.

Já no pacto de compra e venda, a empresa fornecedora recebe o preço (da operadora de cartão de crédito), e só depois de confirmado o pagamento, envia o produto ao consumidor. Não há risco de mora do consumidor em relação à fornecedora, e, por isso, logicamente, não há previsão de multa moratória. **Como justificar a imposição, pelo Judiciário, de uma cláusula penal à empresa, com base no princípio do equilíbrio contratual, se a multa moratória não é por ela cobrada, nem reverterá em seu proveito?**

A circunstância de que o consumidor se utiliza do cartão de crédito como facilitador para adquirir produtos em lojas virtuais, o que é de seu interesse e também da empresa vendedora, por aumentar a possibilidade de meios de pagamento e, portanto, de negócios, não implica a quebra da autonomia entre os contratos de cartão de crédito e o contrato de compra e venda. Assim, não se vislumbra que a imposição da multa contratual para empresa seja um corolário do princípio do equilíbrio contratual entre comprador e vendedor erigido no Código de Defesa do Consumidor.

Observo que a previsão de multa por atraso de entrega de mercadoria, com base na inversão de multa prevista no contrato de financiamento, acarretaria a incongruência, apontada pela recorrente em seus embargos de declaração na origem, de que tal multa somente poderia ser invertida quando prevista, ao menos em tese, ou seja, nas compras a prazo. Assim, o consumidor que comprasse com pagamento à vista, diante do atraso na entrega, não seria beneficiado com a multa, ao contrário do que ocorreria com o consumidor que optasse por parcelar o preço da mercadoria. O absurdo da conclusão demonstra o equívoco da premissa: a multa, acaso existente, diz respeito ao contrato entre o consumidor e financeira, em nada aproveitando ou prejudicando a vendedora, de modo que não há multa contratual a ser contra ela invertida, seja nas compras à vista, seja nas parceladas com o uso do cartão de crédito.

Por mais simpáticos que sejamos à idéia de que os fornecedores de serviços e produtos devam responder pelo atraso no cumprimento de suas obrigações, o fato é que o Código de Defesa do Consumidor não impôs a eles a multa contratual. O art. 49 do CDC dispõe que o fornecedor, nos casos em que o consumidor exercita o direito de arrependimento, deverá restituir imediatamente o valor pago, com atualização. A previsão da atualização monetária pode parecer contraditória se a restituição deve ser imediata; entretanto, denota que pode haver demora no reembolso ao consumidor – mas essa demora não prejudica o equilíbrio da relação de consumo a ponto de demandar a imposição, genérica e abstrata, por lei, de cláusula penal.

Nos casos de atraso na devolução da mercadoria em hipótese de venda

cancelada pelo consumidor no prazo de arrependimento, da mesma forma, o legislador preferiu não instituir regra específica de penalização do consumidor. A experiência indica que, não raro, esse atraso pode ser atribuído a circunstâncias que escapam da seara do fornecedor e do consumidor, como dificuldades encontradas por terceiros que realizam o transporte das mercadorias.

Em suma, o legislador não anteviu quebra no equilíbrio contratual nos casos de atraso na entrega de mercadoria ou restituição decorrente de arrependimento, ao menos não a ponto de lançar mão da imposição da multa contratual ao fornecedor, como norma geral e abstrata. Assim, dado que ao Poder Judiciário não é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a "inversão" da cláusula deve partir do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC. Nenhum desses requisitos se faz presente, data maxima vênia, no caso sob exame.

Anoto que o estímulo ao cumprimento dos prazos para a entrega de mercadorias, e para devolução do pagamento em caso de desistência da compra, não depende da imposição, pelo Judiciário, de cláusula contratual padrão, não prevista em lei e nem pelos contratantes.

Em princípio, é razoável supor que o fornecedor cumpra tais obrigações, tendo como objetivo o seu bom nome comercial. As leis do mercado tendem a punir aqueles que prestam serviço deficiente, e, para tanto, os consumidores dispõem de variados canais na *internet* para tornar públicas suas reclamações e também elogios, o que pode ser mais eficaz do que a ingerência do Poder Judiciário na imposição prévia e abstrata de cláusulas contratuais, por mais bem intencionadas que sejam iniciativas do gênero.

Necessário ressaltar que o consumidor não está desamparado, e sempre pode recorrer ao Poder Judiciário quando, no caso concreto, o atraso na entrega da mercadoria, ou na restituição do preço da compra cancelada, for injustificado e ultrapassar os limites da razoabilidade.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 26/09/2017 JULGADO: 26/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti dando provimento ao recurso especial, divergindo do relator, PEDIU VISTA o Ministro Antonio Carlos Ferreira.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 2251233220088260100 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 28/11/2017 JULGADO: 28/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 28/11/2017 JULGADO: 05/12/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 20/02/2018 JULGADO: 20/02/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.993 - SP (2013/0104421-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Trata-se de recurso especial interposto por KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, contra os acórdãos de fls. 273/288 e 298/304 (e-STJ), do TJSP, assim ementados:

> BEM MÓVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Compra e venda de mercadorias fornecidas por grande empresa através do seu *site* na *internet* – Possibilidade de desistência do negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora – Restituição da quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora – Necessidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do produto – Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros legais de 1% ao mês – Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula penal mas também o fornecedor – Recurso parcialmente provido. (e-STJ fl. 276 – grifei.)
>
> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COISAS – BEM MÓVEL – Ação civil pública – Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora apresenta erro de fato, contradição, obscuridade e omissão – Nítido caráter infringente, sem condições de ser provido, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir – Embargos rejeitados. (e-STJ fl. 300.)

A recorrente, para demonstrar a licitude da conduta, detalha assim o procedimento adotado nas vendas realizadas por meio de sua "loja virtual":

> i. Acessado o site da Kalunga, o comprador, na página inicial, vislumbra as ofertas do dia, bem como *links* de acesso a diversas categorias de produtos (fls. 94/96 dos autos).
> ii. Escolhido o produto, abre-se nova página, com preços e detalhes do produto (fls. 97/98 dos autos).
> iii. Interessado em adquirir um produto, o comprador clica em "comprar", opção que o remete à etapa seguinte.
> iv. O comprador é remetido à página de identificação. Caso seja sua primeira compra no *site*, é necessário que se faça um cadastro, no qual devem constar seu nome, RG, CPF, endereço e *email* de identificação. (fls. 99/101 dos autos).
> v. Identificado o comprador, são apresentadas as transportadoras que prestam serviço para a Kalunga nas diversas regiões atendidas pelo *site*, com os diferentes valores de frete e prazos de entrega do produto. (fls. 90/92 e 102 dos autos).

> vi. Levando em consideração o valor do frete e o prazo de entrega, o comprador escolhe a transportadora e *clica* em "Finalizar Compra".
> vii. O comprador, então, deve escolher a forma de pagamento de sua preferência, a saber (a) cartão de crédito; (b) transferência eletrônica; (c) boleto bancário; (d) faturado (esclusivamente disponível para pessoas jurídicas), conforme documentos juntados às fls. 103/106 dos autos.

Afirma a recorrente que "não há a assinatura de contrato de adesão, com fixação de cláusula penal" (e-STJ fl. 317) e que:

> 11. E, mesmo que fosse firmado um contrato, o que se admite somente para argumentar, não haveria sentido algum fixar uma multa de mora para o comprador, eis que, das quatro formas de pagamento disponíveis – cartão de crédito, transferência eletrônica, boleto bancário e faturado (esta última exclusivamente disponível para pessoas jurídicas) –, as três primeiras não expõem a Recorrente ao risco da mora.
> 12. Com efeito, optando o comprador em cumprir sua obrigação por meio de uma transferência eletrônica ou de um boleto bancário, o pagamento é feito à vista, antes do envio da mercadoria. Somente após a confirmação do pagamento é que abrirá, para a Recorrente, o prazo de entrega do produto, conforme se verifica nos documentos de fls. 88/89 e 103/106 dos autos.
> 13. Efetuado pagamento com a utilização de cartão de crédito, a administradora do cartão passa a ser responsável pelo repasse das quantias à Recorrente, deduzida a *taxa de desconto*. Os riscos de inadimplemento e de mora passam a ser, exclusivamente, da administradora e do emissor do cartão de crédito. Mesmo que o comprador não pague a fatura, as empresas responsáveis pelo cartão estão contratualmente obrigadas a efetuar os repasses à Recorrente.
> 14. E, ao contrário do que supôs o v. Acórdão do Tribunal *a quo*, a Kalunga não está ligada a financeiras, como outras lojas do ramo.
> 15. O que a Kalunga oferece aos consumidores é diversos meios de pagamento. Entre eles, está o pagamento por intermédio de cartão de crédito, no qual a Kalunga informa ao seu consumidor que valores superiores a R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) podem ser parcelados em 3 (três) vezes sem juros (o que não é financiamento, portanto) e parcelados em 10 (dez) vezes com juros.
> 16. Ora, a Kalunga sempre receberá da operadora do cartão de crédito o valor de face da venda. Caso o consumidor opte pelo pagamento parcelado, ou, ainda, caso o consumidor atrase no pagamento da fatura de cartão de crédito, os juros serão pagos por ele à operadora de cartão de créditos. Trata-se, portanto, do equilíbrio do contrato firmado entre consumidor e a administradora de cartão de crédito. (e-STJ fls. 317/318.)

Mais adiante, assevera que, "muito embora exista ligação entre o contrato firmado entre o consumidor e a Kalunga e aquele firmado entre ele e a administradora de cartão de crédito, os equilíbrios econômicos dos contratos distintos não podem, data vênia, serem considerados em conjunto" (e-STJ fl. 318). Acrescenta que "a Kalunga não cobra e nunca receberá os juros ou a multa por atraso no pagamento do preço de seus consumidores. Por conseguinte, com base no princípio do equilíbrio contratual (art. 4º, II, do CDC), não deveria arcar com juros e multa na hipótese de eventual atraso" (e-STJ fl.

318).

Sustenta que o princípio da liberdade contratual não foi extinto pelos novos princípios. Segundo a recorrente, "o Art. 421 do Código Civil começa explicitando o princípio da liberdade contratual, para, somente após, limitá-lo e fundamentá-lo na função social" (e-STJ fl. 318), e inexiste lei "que obrigue a Recorrente a incluir cláusula penal contra si, em ofertas nas quais, ao comprador, não é imposta tal obrigação" (e-STJ fl. 319).

Entende que "não procede a alegação do Recorrido de que, sem a cláusula penal, o disposto no Art. 39, do CDC ficaria *'desvalido juridicamente'*, pois não haveria *'sanção bastante para o seu desrespeito'* (fl. 06 dos autos)" (e-STJ fl. 319). Isso porque "a própria lei que estabelece o dever do devedor de responder *'pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualizações dos valores monetários segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado'* (Art. 395, do Código Civil). O Art. 396, do CC, por sua vez, ressalva que, se não houve *'fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora'*" (e-STJ fl. 320).

Alternativamente, aponta contrariedade aos arts. 2º do CDC e 476 do CC/2002. Esclarece que "o v. Acórdão recorrido condenou a Recorrente *a estabelecer em todas as suas operações de venda de produtos multa moratória para o caso de atraso na entrega a mercadoria, bem como multa moratória para o eventual atraso na restituição do preço pago pelo consumidor, nas hipóteses de arrependimento previstas no art. 49, § único, do CDC, no montante de 2% do valor do produto, além de juros legais de 1% ao mês, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 por consumidor em relação ao qual haja a violação"* (fl. 235 dos autos, g.n.)" (e-STJ fl. 321). No entanto, o TJSP deixou de explicitar "que as vendas feitas exclusivamente a pessoas jurídicas não se encontram abarcadas pelo julgado" (e-STJ fl. 321), o que seria de rigor, tendo em vista que as referidas empresas "não podem ser consideradas como consumidoras, pois não são destinatárias finais fáticas e econômicas dos bens adquiridos (art. 2º do CDC)" (e-STJ fl. 321). Incide, "nos contratos de compra e venda interempresariais" (e-STJ fl. 322), o Código Civil, sendo incabível, em tais relações contratuais, a intervenção do Ministério Público "como substituto processual (art. 82, I, do CDC), para defender os interesses de grandes conglomerados multinacionais, do maior escritório de advocacia do país, e etc." (e-STJ fl. 323).

Especificamente a respeito das vendas faturadas, aduz que também "não seria a hipótese de prever cláusula penal para a Recorrente" (e-STJ fl. 323) pelas seguintes razões:

> 44. Primeiro, porque, como se infere do *site* da Recorrente, não é firmado, com o comprador pessoa jurídica, contrato de adesão algum, bem como não há previsão da cobrança de cláusula penal: a pessoa jurídica compradora somente preenche um cadastro e o envia, à Recorrente, juntamente com a documentação necessária

> (fls. 105/108 dos autos).
> 45. Ademais, no caso de venda faturada, o produto é entregue muito antes do pagamento do preço. Com efeito, os prazos de entrega são de alguns dias úteis, enquanto o prazo de pagamento é igual ou superior a 30 (trinta) dias (fls. 103/104 dos autos). Assim, considerando a regra da interdependência das prestações contratuais (Art. 476 do Código Civil), não há sentido algum a previsão de cláusula penal para obrigação da Apelada, já que esta é cumprida antes de ter ocorrido o cumprimento da contraprestação (pagamento do preço). (e-STJ fls. 323/324.)

Insurge-se, ainda, contra o valor da multa, nos seguintes termos:

> 47. Em qualquer caso acima, há que ser diminuída a multa fixada para o caso de descumprimento da condenação, eis que absolutamente exorbitante.
> Com efeito, a cominação de multa em R$ 10.000,00 para cada eventual descumprimento na fixação de multa moratória, num universo de milhares de vendas é absolutamente exagerado e desproporcional ao descumprimento em questão.
> Diante disso, requer-se seja reformado o v. acórdão nesse ponto diminuindo-se o valor da multa por descumprimento.

Por último, argumenta que, "apesar (i) de terem sido expressamente mencionados nas razões da Apelação; (ii) de ter sido demonstrada nos fundamentos expendidos no v. acórdão recorrido a negativa de vigência dos referidos dispositivos legais; e (iii) de ter o Recorrente oposto embargos de declaração, alegando que os artigos em questão não foram referidos de maneira expressa no v. acórdão recorrido, o órgão rejeitou os embargos, afirmando que *'não padece o acórdão de qualquer omissão a ser sanada'*" (e-STJ fls. 324/325). Em tal contexto, caso se entenda que os dispositivos legais carecem de prequestionamento, deve o recurso especial ser provido por afronta ao art. 535, II, do CPC/1973.

A título de conclusão, afirma que "restou clara [...] a negativa de vigência aos arts. 535, do Código de Processo Civil, 4º, III, 39, XII, 49, 51, IV, e 51, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor; 395, 396, 421 e 476, do Código Civil" (e-STJ fl. 326).

Pede, então, (i) seja afastada "a necessidade de fixação de multa moratória" (e-STJ fl. 320); ou (ii) sejam fixados "os limites da condenação, que deverão ser apenas àquelas compras efetivadas por pessoas físicas fora do estabelecimento, no *site* da empresa e por meio de financiamento com cartão de crédito" (e-STJ fl. 324); ou (iii) seja reduzida a multa por descumprimento (cf. e-STJ fl. 324); ou (iv) caso se reconheça ausente o prequestionamento das normas indicadas como contrariadas, seja acolhido o recurso com fundamento na violação do art. 535, II, do CPC/1973 (cf. e-STJ fl. 324).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, autor da ação civil pública, apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 337/347), e o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fl. 356), tendo seguimento nesta Corte Superior em decorrência do provimento do AREsp n. 325.758/SP (e-STJ fl. 388).

O Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS, ilustrado Subprocurador-Geral da República, reportou-se à manifestação do *parquet* estadual, aguardando o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-STJ fl. 396).

O em. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator, negou provimento ao recurso especial. Destacou Sua Excelência os princípios e as regras contidos nos arts. 4º, III, 6º, II, 7º, 39, 49 e 51, IX, XI e XII, do CDC, citando, ainda, lições de Eros Roberto Grau a respeito da interpretação teleológica e finalística do referido Código, a Portaria n. 4, de 13.3.1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ) e, a título de ilustração, a Diretiva n. 93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Européia (CEE), de 5.4.1993, concluindo em seu voto que:

> Assim, a meu juízo, seja por princípios gerais do direito, ou pela linha adotada no Código, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor – em situações análogo descumprimento da avença.
> Assim, penso que, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento.
> [...]
> Ressalte-se, ademais, que não prospera a alegação da recorrente no sentido de que a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal nas compras a vista, pelo simples motivo de inexistir risco de mora, uma vez que as vendas pela *internet* são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito, de modo que somente após a confirmação do pagamento é que começa a correr o prazo para a entrega do produto.
> A assertiva da recorrente, em verdade, corre em seu desfavor, uma vez que não é difícil alcançar o raciocínio de que, na verdade, a recorrente não precisa da imposição de multa para garantia do cumprimento da obrigação pelo consumidor, já que, enquanto ele não aperfeiçoa sua obrigação (paga o preço), a recorrente não cumpre sua tarefa de entregar o produto. Não há razão na instituição da multa nas compras a vista, portanto.
> Da mesma forma, não prospera a alegação da recorrente no sentido da impossibilidade de imposição de multa em seu desfavor, tendo em vista esta a cargo do consumidor é arbitrada por instituição financeira, sendo aquela a verdadeira responsável pelo contrato de financiamento oferecido aos compradores da loja virtual.
> Não há como acolher aludido argumento porque, em última análise, e indiscutivelmente, tal financiamento é manifesto incentivador/facilitador dos negócios que se realizam no ambiente virtual. A recorrente tem pleno conhecimento de que não fosse a opção oferecida de compras via cartão de crédito, em parcelas, ou outro tipo de financiamento, suas vendas seriam sensivelmente diminuídas. Ou seja, interessa ao fornecedor a opção de pagamento consubstanciado naquele financiamento que a recorrente afirma ser titularizado por pessoa diversa.
> Ademais, há de se considerar que ao contratar tal forma de pagamento, o consumidor não tem em mente que contrata com pessoa diferente da recorrente varejista que dá nome à loja na qual "entrou" para realizar suas compras! Não é

> com a financeira que o consumidor, ao menos *deseja* contratar, mas com a fornecedora dos produtos, no caso, a Kalunga Comércio e Indústria.

Citou, também, recente julgado da TERCEIRA TURMA, proferido no REsp n. 1.548.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 6.9.2017.

A em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI proferiu voto-vista dando provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido. Argumentou, de início, que relativamente "à imposição da multa por parte da empresa, o acórdão é obscuro, apontando os documentos de fls. '94/105' (fls. 122/133 e-STJ) como indicativos dessa cobrança. Esses documentos, todavia", segundo a em. Ministra, "são apenas cópias impressas de várias telas da loja virtual da empresa, em que se encontram descritas várias formas de pagamento com suas especificações, sem se referirem uma única vez à cobrança de cláusula penal ou multa moratória". A respeito desse aspecto fático, concluiu que "o acórdão estaria se referindo à forma de pagamento por meio de cartão de crédito. As outras modalidades dizem respeito a pagamento à vista e faturado – este último, apesar da possibilidade de parcelamento, também não apresenta referência alguma à multa moratória, sendo, ademais, privativo de clientes pessoas jurídicas, aos quais negada a proteção do CDC pelo próprio acórdão recorrido". No mérito, afirma que "a loja permite a utilização de diversas bandeiras de cartão de crédito" e "em nenhum momento foi investigado se todas essas operadoras cobram a referida multa, e em que percentual". Em tal contexto, "a imposição da multa ao consumidor quando do inadimplemento" decorreria "de uma suposição, e o seu percentual, nos casos em que efetivamente cobrada, é incerto". Asseverou também "que o contrato de cartão de crédito não pode ser chamado de acessório ao pacto de compra e venda, a não ser no sentido mais lato do vocábulo, de servir como instrumento para a realização do negócio. Na verdade se trata de pactos autônomos, com fornecedores de serviços diversos (compra e venda e financeiro) e cláusulas diferentes e incomunicáveis". Nesse sentido, o contrato de cartão de crédito não poderia "ser considerado 'umbilicalmente' ligado ao contrato de compra e venda. O consumidor dispõe de diversos outros meios de pagamento, [...] e, portanto, não" dependeria "apenas de determinado cartão para efetuar compra no *site* da recorrente, sendo, ademais, diversas as bandeiras de cartão aceitas como meio de pagamento". Ressaltou inexistir desequilíbrio contratual no pacto celebrado entre o consumidor e a operadora do cartão, tendo em vista "que a cobrança de encargos moratórios é contrapartida contratual e legalmente prevista diante da mora do consumidor, que obteve o crédito de forma fácil e desembaraçada, sem prestar garantia adicional alguma além da promessa de pagar no prazo acertado". Explicitou que:

> Quebra de contrato pela administradora do cartão haveria se esta se desincumbisse da obrigação assumida com o consumidor de autorizar a compra e repassar o pagamento ao vendedor do produto. Mas disso não se cogita na

> presente ação civil pública, a qual não se volta contra a administradora ou financeira do cartão de crédito.
> Já no pacto de compra e venda, a empresa fornecedora recebe o preço (da operadora de cartão de crédito), e só depois de confirmado o pagamento, envia o produto ao consumidor. Não há risco de mora do consumidor em relação à fornecedora, e, por isso, logicamente, não há previsão de multa moratória. Como justificar a imposição, pelo Judiciário, de uma cláusula penal à empresa, com base no princípio do equilíbrio contratual, se a multa moratória não é por ela cobrada, nem reverterá em seu proveito?
> [...]
> Em suma, o legislador não anteviu quebra no equilíbrio contratual nos casos de atraso na entrega de mercadoria ou restituição decorrente de arrependimento, ao menos não a ponto de lançar mão da imposição da multa contratual ao fornecedor, como norma geral e abstrata. Assim, dado que ao Poder Judiciário não é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a "inversão" da cláusula deve partir do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC. Nenhum desses requisitos se faz presente, data maxima vênia, no caso sob exame.

A riqueza dos votos proferidos me fizeram pedir vista destes autos.

Data maxima venia, apesar dos doutos fundamentos apresentados pelo em. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator, acompanho a divergência, inaugurada pela em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, não havendo muito para acrescentar à fundamentação do voto de Sua Excelência.

A relação negocial questionada diz respeito a um contrato padrão contido no *site* da loja virtual da ré, com previsão de diferentes modalidades de pagamento, dentre as quais encontra-se a opção do uso de cartão de crédito.

A questão jurídica tratada nestes autos demanda, primordialmente, verificar se os contratos de compra e venda e de financiamento podem ser examinados separadamente e considerados independentes para efeito de se aplicar a reciprocidade de cláusulas contratuais disciplinada no Código consumerista. Isso porque a previsão de multa encontra-se atrelada apenas ao pagamento mediante a utilização de cartão de crédito.

Sob esse enfoque, o acórdão recorrido confirma a existência de multa contratual na hipótese de financiamento pelo consumidor, assim:

> Aduziu a ré na contestação, que a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal porquanto inexiste risco de mora, uma vez que as vendas pela *internet* são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito, de modo que somente após a confirmação do pagamento é que começa a correr o prazo para a entrega do produto.
> Entretanto, com a devida vênia, na hipótese em testilha, vislumbra-se a cobrança de multa moratória em caso de atraso no pagamento do preço do produto por parte do consumidor, eis que há financiamento oferecido pela ré em seu *site*, para compra das mercadorias em parcelas, como se vê dos documentos de fls. 94/105.
> [...]

> Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade e rompimento do equilíbrio contratual. (e-STJ fls. 285/286.)

O contexto fático apresentado impõe sejam examinadas separadamente as relações entre o fornecedor do produto, o consumidor e a operadora do cartão de crédito.

O cartão de crédito é um meio que possibilita o pagamento (à vista ou parcelado) de produtos e serviços e visa a promover o mercado de consumo, facilitando as operações de compra.

A relação jurídica obrigacional havida entre o consumidor e a operadora do cartão é independente e preexistente àquela estabelecida entre o consumidor e os estabelecimentos credenciados.

A recorrente, ao meu ver, apenas permite que o consumidor efetue o pagamento de suas compras mediante a utilização de cartão de crédito, dentre outras opções que lhe são apresentadas.

Com isso, cláusulas inseridas no contrato de cartão de crédito não contaminam nem podem ser consideradas como causa de desequilíbrio no posterior contrato de compra e venda. A propósito, o consumidor adere ao contrato de cartão de crédito para realizar compras com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que aceitem tal forma de pagamento, sendo inviável que tais pessoas sejam obrigadas a adaptar o próprio contrato de compra e venda de bens ou serviços aos contratos de cada instituição financeira.

O fato de a operadora de cartões poder cobrar multa do consumidor por atraso na quitação das faturas, portanto, deve ser considerado, para efeito de equilíbrio contratual, apenas no âmbito do próprio contrato financeiro.

A ora recorrente, que não financia diretamente as sua vendas e que, por isso, não inseriu no contrato de compra e venda à vista penalidade de multa em desfavor do consumidor, não pode ser compelida a recolher verbas de natureza punitiva para as hipóteses de atraso na entrega da mercadoria e na restituição do preço no caso de arrependimento disciplinado no art. 49, parágrafo único, do CDC.

É evidente que a desistência do negócio, garantida pelo CDC, repercute no pagamento do preço efetuado mediante o uso do cartão de crédito, com o correspondente estorno dos lançamentos, e devolução dos valores eventualmente pagos, corrigidos monetariamente, sem qualquer ônus para o consumidor.

Hipótese diversa seria aquela em que a própria vendedora financiasse, com capital próprio, os contratos de compra e venda e estabelecesse cláusulas penais para os casos de inadimplemento por parte do adquirente das mercadorias, ou se o consumidor fosse obrigado a celebrar, no mesmo momento, os contratos de compra e venda e de

cartão de crédito, ambos apresentados pelo vendedor do produto, caracterizando inclusive venda casada. Tais circunstâncias, no entanto, não se verificam neste caso, não se podendo considerar cláusulas do anterior contrato de cartão de crédito para efeito de reconhecer desequilíbrio na negociação comercial realizada com a ora recorrente.

A operadora do cartão de crédito não pertence à ora recorrente nem está caracterizado grupo econômico que abranja as duas pessoas jurídicas, sendo os respectivos contratos autônomos entre si, celebrados em épocas distintas e sem interferências recíprocas.

Ante o exposto, *data maxima venia* do em. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator, acompanho a divergência inaugurada pela em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 20/02/2018 JULGADO: 06/03/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso especial, acompanhando a divergência, PEDIU VISTA dos autos o Ministro Marco Buzzi.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.993 - SP (2013/0104421-7)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:

Trata-se de recurso especial interposto por KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 273/288, e-STJ):

> BEM MÓVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Compra e venda de mercadorias fornecidas por grande empresa através do seu site na *internet* - Possibilidade de desistência do negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora - Restituição da quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora - Necessidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do produto - Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros legais de 1 % ao mês - Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula penal, mas também o fornecedor - Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos.

Em suas razões (fls. 307/326, e-STJ), a recorrente aponta violação, pelo acórdão estadual, aos arts. 535 do CPC/73; 4º, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e, por fim, 395, 396, 421 e 476 do Código Civil.

A empresa defende, em apertada síntese, além da negativa de prestação jurisdicional, a licitude de sua conduta em relação às vendas realizadas por cartão de crédito, fora do estabelecimento físico, no âmbito do seu sítio eletrônico de vendas. Aduz, também, a inviabilidade de imposição de fixação de multa moratória para o caso de atraso na entrega da mercadoria, bem como na hipótese de demora na restituição do preço do produto pago pelo consumidor quando exerce o direito de arrependimento, porquanto viola o princípio do equilíbrio contratual.

Contrarrazões às fls. 337/347 (e-STJ).

Inadmitido o apelo nobre na origem, o e. Ministro Relator deu provimento ao agravo (art. 544 do CPC/73) para melhor examinar a matéria (fls. 388, e-STJ).

Levado a julgamento, na assentada do dia 27 de junho de 2017, o Ministro Luís Felipe Salomão **negou provimento** ao reclamo, mantendo a multa moratória de

2% (dois por cento) sobre o valor da mercadoria, nos casos de atraso envio do produto informado e, também, de devolução do valor da mercadoria ante o direito de arrependimento exercido pelo consumidor.

Fundamentou, para tanto, que: a) a inserção de cláusulas no pacto de adesão é providência que atende ao equilíbrio contratual, pois o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade; b) em caso semelhante, julgado pela Terceira Turma do STJ, nos autos do **REsp 1.548.189/SP** (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSERVERINO, DJe 06/09/2017), restou mantida a multa moratória imposta, conforme estabelecido pela Corte Estadual; c) é reconhecida pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça a abusividade de disposições negociais que imponham apenas ao consumidor sanções pelo descumprimento das obrigações avençadas; d) existe precedente deste Tribunal Superior no sentido de estender a multa moratória ao vendedor inadimplente, quando a referida penalidade não estava estipulada no acordo originalmente firmado entre as partes (**REsp 955.134/SC**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012); e) a recorrente se aproveita da facilidade de oferecer pagamento por meio de cartão de crédito para fomentar as suas vendas; e, f) a tramitação de projeto de lei, na Câmara dos Deputados, visando dar efetividade às regras protetivas do direito do consumidor quanto atua no comércio eletrônico, corrobora a responsabilidade da loja varejista.

Por sua vez, a e. Ministra Maria Isabel Gallotti abriu a **divergência** ao apresentar, na sessão de julgamento do dia 29 de setembro de 2017, o seu voto-vista, dando provimento ao apelo e, por conseguinte, restabelecendo a sentença de improcedência. Ao apresentar seus motivos, asseverou: a) a inaplicabilidade do precedente firmado no **REsp 955.134/SC**, ante a existência expressa no pacto de cláusula penal estipulada apenas em favor do vendedor; e, b) a multa, acaso existente, diz respeito ao contrato entre o consumidor e a financeira, em nada aproveitando ou prejudicando a vendedora, de modo que não há sanção contratual a ser contra ela invertida, seja nas compras efetuadas no sítio eletrônico à vista ou, também, naquelas parceladas com o uso do cartão de crédito.

Prosseguindo a deliberação do órgão colegiado, o e. Ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista dos autos, tendo, posteriormente, em 06 de março de 2018, apresentado suas conclusões e acompanhado a divergência, o que justificou o meu pedido de vista, para melhor exame da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo, como restou fundamentado pelo e. relator, **não merece** prosperar.

A controvérsia ora em foco, resumidamente, consiste em decidir se é possível condenar o fornecedor por multa moratória em contratos celebrados entre consumidores e empresa de comércio varejista, nas hipóteses em que descumprir o prazo ajustado para a entrega dos produtos que comercializa, bem como quando igualmente transpassar o termo fixado de restituição dos valores pagos pelo consumidor, exercido, nos termos da lei protecionista, o seu direito de arrependimento.

1. Em que pese os argumentos apresentados pela divergência, a situação acima retratada encontra-se regulada na regra inserta do art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual nos contratos consumeristas deve haver reciprocidade de direitos entre os envolvidos, revelando-se abusivas, como no caso, as cláusulas contratuais que obriguem o consumidor a ressarcir os custos da cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.

Essa, aliás, foi a deliberação tomada pelo colegiado da Terceira Turma do STJ, em idêntico caso, no julgamento do **REsp n.º 1.548.189/SP** (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 06/09/2017), no qual restou firmado o entendimento no sentido de que é possível "*a intervenção judicial nos contratos padronizados de consumo de modo a restabelecer o sinalagma negocial, fazendo incidir a mesma multa prevista para a mora do consumidor nos casos de atraso na entrega dos produtos ou de devolução imediata dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento, com fundamento tanto no CDC, como no próprio Código Civil (arts. 395, 394 e 422) ao estatuir os efeitos da mora e a submissão dos contratantes à boa-fé objetiva*".

A possibilidade de reversão da penalidade imposta contratualmente, de forma unilateral ao consumidor, aliás, encontra-se rotineiramente consagrada e aplicada pelo Tribunal da Cidadania, porquanto, inegavelmente, a existência de cláusula favorável, unicamente, a uma das partes, ocasiona nítido desequilíbrio contratual. Nesse sentido, dentre outros, cita-se os seguintes precedentes: **REsp 955.134/SC**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012; **AgInt no AgInt no REsp 1605486/DF**, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016; **REsp 1.665.550/BA**, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017; e, **AgInt nos EDcl no AREsp 1.010.004/RJ**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017.

A rede protetiva assegurada ao consumidor em nossa legislação deve ser igualmente aplicada nas condutas empresariais atinentes ao comércio eletrônico, onde, ressalte-se, a vulnerabilidade do usuário é ainda mais evidente, estando sujeito a contratos de adesão, por vezes abusivos, e vinculado à má ou deficiente informação sobre os termos neles inseridos.

Nesse viés, como ressaltou o e. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, "*a inserção nos contratos, como dos autos, da multa moratória visa, acima de qualquer coisa, garantir ao consumidor o cumprimento perfeito da avença, a não frustração de suas expectativas*", mormente porque o prazo de entrega somente começa a ser contado para a empresa após a confirmação bancária de que houve o efetivo pagamento.

Ora, nas vendas efetuadas por sítios eletrônicos de comércio de bens de consumo não é crível desconsiderar a teoria da aparência na solução da presente questão, pois, em se tratando de contratos coligados (venda e financiamento), como bem leciona NELSON ROSENVALD, em razão de sua indissociável conexão, "*a validade e a eficácia de um contrato dependerão da validade e da eficácia do outro, pois cada um é a causa do outro*", de modo que "*o destino de ambos os contratos está ligado não só na sua formação, como também no desenvolvimento e no funcionamento das respectivas relações*" (Obra: **Manual de Direito Civil**, volume único. Salvador: Editora JusPodivm, p. 946).

Idêntica conceituação e consideração, inclusive, é reproduzida pela jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "*os contratos coligados são aqueles que, apesar de sua autonomia, se reúnem por nexo econômico funcional, em que as vicissitudes de um podem influir no outro, dentro da malha contratual na qual estão inseridos*" (**REsp 1.141.985/PR**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014).

Confira-se, ainda, sobre o tema, o elucidativo precedente desta Colenda Quarta Turma,a seguir transcrito:

> RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS

PLANEJADAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR RESCINDIDOS OS CONTRATOS E CONDENAR OS RÉUS (LOJISTA, FABRICANTE E BANCO), SOLIDARIAMENTE, A DEVOLVER AOS AUTORES AS QUANTIAS DESPENDIDAS, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA - CONTRATO COLIGADO AMPARADO EM CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA ENTRE O BANCO E O FORNECEDOR DOS BENS EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTO, POR MEIO DA QUAL PASSOU A CASA BANCÁRIA A FIGURAR COMO EFETIVA CREDORA DOS VALORES REMANESCENTES A SEREM PAGOS PELOS CONSUMIDORES (PRESTAÇÕES), DEDUZIDO O VALOR DA ENTRADA/SINAL - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CASA BANCÁRIA NO TOCANTE À INTEGRALIDADE DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS AUTORES, REMANESCENDO O DEVER DE RESTITUIR OS IMPORTES RECEBIDOS MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

[..]

3.1 O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um único documento, pois é a substância do negócio jurídico que lhe dá amparo, não a forma.

3.2 Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com o fornecedor das cozinhas quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual possível a arguição da exceção de contrato não cumprido, uma vez que a posição jurídica ativa conferida ao consumidor de um produto financiado/parcelado relativamente à oponibilidade do inadimplemento do lojista perante o agente financiador constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento.

3.3 Entretanto, a ineficácia superveniente de um dos negócios, não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação.

3.4 Assim, a interpretação contratual constitui premissa necessária para o reconhecimento da existência e para a determinação da intensidade da coligação contratual, o que no caso concreto se dá mediante a verificação do *animus* da casa bancária na construção da coligação e o proveito econômico por ela obtido, pois não obstante o nexo funcional característico da coligação contratual, cada um dos negócios jurídicos

> entabulados produz efeitos que lhe são típicos nos estritos limites dos intentos dos participantes.
> 3.5 Inviável responsabilizar solidariamente a financeira pelos valores despendidos pelos consumidores, uma vez que, ao manter o contrato coligado, não se comprometeu a fornecer garantia irrestrita para a transação, mas sim balizada pelos benefícios dela advindos, ou seja, no caso, nos termos da cessão de crédito operada, que não abarca os valores pagos à título de entrada diretamente ao lojista.
> 3.6 A circunstância de o contrato de financiamento sucumbir diante do inadimplemento do lojista não transforma a casa bancária em garante universal de todos os valores despendidos pelos autores, principalmente porque a repetição do indébito limita-se àquilo que efetivamente foi desembolsado - seja dos consumidores para com a financeira, seja desta para com a lojista. A responsabilidade do banco fica limitada, portanto, à devolução das quantias que percebeu, pois a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes.
> 4. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido, para afastar a responsabilidade solidária da casa bancária pela repetição integral dos valores despendidos pelos consumidores, abarcando aquele pago a título de entrada no negócio de compra das cozinhas planejadas, remanescendo a responsabilidade do banco na devolução atualizada dos valores recebidos por meio dos boletos bancários, em razão da cessão do crédito restante (crédito cedido pela lojista não abrangendo o valor recebido por esta última a título de entrada no negócio), pois as vicissitudes de um contrato repercutiram no outro, condicionando-lhe a validade e a eficácia.
> (**REsp 1127403/SP**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 15/08/2014)

Com efeito, as condições de pagamento, nesse tipo de negociação, são estipuladas e repassadas nos termos da fornecedora do produto, diretamente em sua plataforma, contendo elementos fáticos suficientes, portanto, para induzir o consumidor na crença de que a avença é celebrada diretamente com a loja varejista.

Assim, no mínimo, os contratos de compra e venda ofertados pela loja varejista e de seu financiamento, por serem coligados, revelam a existência de uma relação obrigacional que, sob o olhar do consumidor vulnerável, pode ser perfeitamente entendida como um único ato negocial, razão pela qual, no ponto, é imperioso trazer ao conhecimento a lição do professor LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, saudoso mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, no sentido que "*os contratos coligados de dependência unilateral caracterizam-se pela acessoriedade de um em relação ao outro. Ou seja, um contrato só tem sentido se um primeiro contrato existir*" (Obra: **Redes contratuais e contratos coligados**. *In:* Direito Contratual Temas Atuais. Coordenação de Flávio Tartuce. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 477).

2. Na hipótese, ademais, como ressaltou o Ministro Luís Felipe Salomão, há um desequilíbrio contratual que deve ser tutelado pela legislação consumerista, ante a integração sistêmica do **princípio da vulnerabilidade** (art. 4º, I, do CDC), porquanto este, como é sabido, decorre de duas premissas que, no caso, encontram-se perceptíveis: **a**) a primeira, de ordem técnica, é nítida a sobreposição do fornecedor varejista ao consumidor, em razão de deter exclusivamente as informações dos serviços prestados e não repassá-las de forma clara e adequadamente; e, **b**) a segunda, de ordem econômica, é díspar a capacidade econômica entre os contratantes.

A vulnerabilidade jurídica, portanto, emana das dificuldades que os consumidores encontram para defender os seus direitos junto aos fornecedores, de forma que compete à lei suprir o desequilíbrio contratual gerado indevidamente no caso, haja vista a previsão exclusiva ou unilateral de obrigações para a parte hipossuficiente da relação, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, constatada a desigualdade entre as partes contratantes, no âmbito do direito do consumidor, não há como preterir a participação judicial mais incisiva no cerne da relação negocial com o objetivo de diminuir a discrepância existente entre os envolvidos, equilibrando, de conseguinte, a relação contratual estabelecida.

Deste modo, o estabelecimento equânime de multa moratória à recorrente, por atraso no envio do produto ou na restituição do valor pelo arrependimento do consumidor, como deliberou a instância ordinária, não é descabida.

3. Concluindo, com amparo nos fundamentos acima alinhavados, em concordância com a posição firmada pelo relator e, ainda, pedindo vênia à divergência, entende-se que não prospera a alegação da empresa varejista no sentido da inviabilidade de imposição de multa em seu desfavor, ao argumento de a penalidade é arbitrada, na impontualidade do consumidor, não por ela, mas pela instituição financeira.

4. Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso especial.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 24/04/2018 JULGADO: 24/04/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso especial, acompanhando o relator, PEDIU VISTA o Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região).

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 24/04/2018 JULGADO: 03/05/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Lázaro Guimarães.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.993 - SP (2013/0104421-7)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO : RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO):

Trata-se de recurso especial manejado por KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento a recurso de apelação para julgar procedente, em ação civil pública, pedido aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, aqui recorrido, impondo à ora recorrente a previsão, em seus contratos de adesão, de cláusula penal, genérica e abstrata, para pagamento de multa em decorrência de eventuais atrasos na entrega de mercadoria vendida através da rede mundial de computadores e na devolução de quantia paga pelo comprador na hipótese de arrependimento prevista no art. 49 do CDC.

O julgamento do apelo nobre foi iniciado na sessão de julgamento ocorrida em 27 de junho de 2017, oportunidade na qual o ilustre relator **Min. Luis Felipe Salomão** votou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo nobre. O julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pela douta **Min. Maria Isabel Gallotti**, que inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso especial, julgando improcedente o pedido. Os doutos **Ministros Antonio Carlos Ferreira** e **Marco Buzzi** também pediram vista dos autos. O primeiro acompanhou o voto divergente; o segundo, por sua vez, seguiu o relator.

Com a votação empatada, pedi vista dos autos para uma melhor análise das questões discutidas.

O ponto nodal da discussão devolvida a esta Corte Superior reside na necessidade de impor em desfavor da recorrente, em seus contratos de adesão, previsão de sanção pecuniária por eventual atraso na entrega de mercadorias vendidas a distância, pela internet, bem como por demora no reembolso na hipótese de arrependimento do comprador, na forma prevista no art. 49 do Código Defesa do Consumidor, em nome do princípio do equilíbrio contratual, consagrado no art. 4º, III, do mesmo diploma legal.

O eg. Tribunal local considerou a existência de duas premissas, quais sejam: (I) a

previsão de cobrança de encargos moratórios em favor do fornecedor para o caso de impontualidade do consumidor quanto ao pagamento do preço; e (II) a impossibilidade de sanções, em caso de atraso ou descumprimento da obrigação, apenas em desfavor do consumidor, para concluir que a recorrente deveria ser forçada a incluir, em seus contratos de adesão, cláusula penal em seu desfavor para o caso de atrasos na entrega de produtos e na restituição do preço na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre o direito de arrependimento nas compras feitas a distância.

A propósito, transcrevo as seguintes passagens do v. acórdão recorrido:

> *"Da leitura da petição inicial, é de se observar que o ilustre Promotor de Justiça do Consumidor menciona a Portaria n° 04, de 13.03.1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que prevê serem nulas de pleno direito as cláusulas que 'estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da obrigação somente em desfavor do consumidor' (fls. 08).*
>
> *Discorre o eminente Promotor de Justiça acerca do desequilíbrio contratual entre os consumidores lé a fornecedora Kalunga, tendo em vista a multa moratória cobrada pelo atraso no pagamento das prestações, afirmando que 'não se conhece contrato de consumo em que a mora do consumidor não seja evento, sujeito a multa moratória - que, nos termos do art. 52, § 2°, do CDC, não pode superar 2% do valor da obrigação em atraso' (fls. 07).*
>
> ***Aduziu a ré na contestação, que a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal porquanto inexiste risco de mora, uma vez que as vendas pela internet são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito, de modo que somente após a confirmação do pagamento é que começa a correr o prazo para a entrega do produto.***
>
> ***Entretanto, com a devida vênia, na hipótese em testilha, vislumbra-se a cobrança de multa moratória em caso de atraso no pagamento do preço do produto por parte do consumidor, eis que há financiamento oferecido pela ré em seu site, para compra das mercadorias em parcelas, como se vê dos documentos de fls. 94/105.***
>
> *Ora, como bem asseverou o ilustre Promotor de Justiça por ocasião da réplica, 'irrelevante que a multa moratória devida pelo consumidor reverta em beneficio da financeira. A ré fala do financiamento - no caso de pagamento parcelado - como se absolutamente nada tivesse com o negócio.*
>
> *Mas o financiamento do preço, ainda que realizado por instituição financeira, é (...) negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria. O financiamento é oferecido por ela própria, notadamente em seu sítio de Internet, como demonstram os documentos que acompanham a contestação" (fls. 119).*
>
> *Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o*

> *consumidor, cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade é rompimento do equilíbrio contratual."* (fls. 285/286)

Sem embargo de entendimentos contrários, percebe-se que o contrato de compra e venda, na relação consumerista sob exame, somente se perfectibiliza mediante a confirmação do pagamento pelo comprador, seja em quaisquer das três hipóteses previstas (transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito), iniciando-se, a partir daí, a obrigação da fornecedora de entregar o produto na forma e tempo contratados, de modo que não há previsão de sanção ao consumidor por atraso ou descumprimento da obrigação.

Com efeito, a multa moratória a que o Ministério Público se refere na ação civil pública, bem como mencionada pelo v. acórdão recorrido, diz respeito à sanção prevista no contrato de concessão de crédito entabulado pelo consumidor com a instituição financeira operadora do cartão de crédito, que é cobrada por esta em seu benefício, contrato esse, aliás, sujeito a regras próprias, especialmente, como cediço, no tocante à política de cobrança de juros, sem guardar relação com as vendas realizadas, a distância, pela recorrente.

Logo, ante a ausência de estipulação de cláusula penal em desfavor do comprador/consumidor, em contratos dessa natureza, a inexistência de previsão contratual, genérica e abstrata, para pagamento de multa por inobservância dos prazos de entrega de mercadoria e de restituição do preço não ofende o multicitado princípio do equilíbrio contratual. Não há falar, portanto, em "inversão" de cláusula penal ou em reciprocidade de cláusulas contratuais disciplinadas na legislação consumerista, revelando a insubsistência, *data maxima venia*, do fundamento utilizado para justificar a condenação imposta à recorrente.

Diante do exposto, peço *venia* ao relator para acompanhar a divergência, no sentido de dar provimento ao recurso especial, julgando improcedente o pedido inicial.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0104421-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.412.993 / SP**

Números Origem: 02251233220088260100 22512332200882601 00 5830020082254123 990092709461

PAUTA: 24/04/2018 JULGADO: 08/05/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Relatora para Acórdão
Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO ARANTES BARCELLOS E OUTRO(S) - SP154361
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Ministro Lázaro Guimarães dando provimento ao recurso especial, acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrará o acórdão.

Vencidos o relator e o Ministro Marco Buzzi.

Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região).